

1500067-92.2022.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/11/2022

... pelas denúncias anônimas. Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de entorpecentes - Demonstração de união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 Lei n. 11.343/06 É de rigor a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 sempre que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

1ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº 1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500067-92.2022.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-92.2022.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069015/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 23556791 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2069015 - DEL.POL.PAULICEIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINSON DOS SANTOS MENEZES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Vistos.

ALTIÉRIS DE SOUZA SILVA e WELLINSON DOS SANTOS MENEZES estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso V; e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, isso porque, segundo a denúncia (fls. 230/232): No dia 12 de março de 2022, período da madrugada, na Rodovia BR 158, Km 2, próximo a ponte interestadual, na cidade de Pauliceia, nesta comarca de Panorama, ALTIÉRIS DE SOUZA SILVA e WELLINSON DOS SANTOS MENEZES, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios, entre si, transportavam, para fins de entrega a terceiros, massa líquida de 27,81 g (vinte e sete gramas e oitenta uma centigramas) de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha (cf. laudos periciais de f. 41-45 e 215-217) e o total de massa líquida de 8,05 g (oito gramas e cinco centigramas) de cocaína (cf. laudos de f. 46-62, 212-214 e 215-217),

substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, oriunda de Brasilândia, MS, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nessas mesmas circunstâncias de tempo e local, ALTIÉRIS DE SOUZA SILVA e WELLINSON DOS SANTOS MENEZES associaram-se, entre si, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Segundo se apurou, os denunciados associaram-se para o cometimento do crime de tráfico de drogas, sobretudo, transportando entorpecente do Estado de Mato Grosso do Sul para revenda no Estado de São Paulo.

Com evidente animus associativo, caracterizado pela estabilidade e permanência, e nítida divisão de tarefas, o DENUNCIADO ALTIÉRIS era o responsável por transportar o entorpecente do vizinho estado, sendo que se utilizava de seu veículo VW Fox, enquanto que WELLINSON, além de auxiliar ALTIÉRIS no transporte da droga, as entregava aos consumidores.

Nesse contexto, previamente ajustados, e em unidade de desígnios, na data dos fatos, os DENUNCIADOS saíram de Brasilândia, MS, conduzindo o veículo VW Fox, de propriedade de ALTIÉRIS, no qual transportavam porções de cocaína e de maconha, para fins de entrega a terceiros, no Estado de São Paulo.

Ocorreu que policiais militares faziam patrulhamento de rotina nas proximidades da ponte que liga o Estado de São Paulo e o Estado de Mato Grosso do Sul, momento em que avistaram um veículo VW Fox atravessando a ponte sentido Mato Grosso do Sul/ Estado de São Paulo, e deram sinal de parada.

A seguir, os policiais constataram que o veículo era conduzido pelo DENUNCIADO ALTIÉRIS e tinha como passageiro o DENUNCIADO WELLINSON, sendo que em revista no veículo os policiais lograram encontrar uma pochete, em cujo interior havia porções de maconha e cocaína, bem como uma porção de uma substância esbranquiçada, uma balança de precisão e a quantia de R\$ 250,00.

Ao serem indagados os DENUNCIADOS, muito embora tenham negado que a droga se destinava a traficância, alegaram que a substância branca se tratava de ácido bórico e seria utilizada para misturar com a cocaína e fazer render o entorpecente. Regularmente apreendidos os entorpecentes e submetidos a exame preliminar de constatação, apurou-se tratar-se de maconha com massa líquida de 27,81 g (vinte e sete gramas e oitenta uma centigramas) (cf. laudos periciais de f. 41-45 e 215-217) e cocaína com massa líquida total de 8,05 g (oito gramas e cinco centigramas).

Assim, as circunstâncias do flagrante, a diversidade e quantidade da droga apreendida, a sua forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e quantia em espécie, bem como a substância esbranquiçada apreendida, que embora não seja entorpecente é utilizada para misturar com cocaína; demonstram que a droga apreendida se destinava ao comércio interestadual de drogas praticado em associação por ALTIÉRIS e WELLINSON.

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 01/02), sendo a prisão convertida em preventiva pela decisão constante às fls. 98/102.

A denúncia foi recebida em 13/04/2022. Na mesma oportunidade, foi autorizada a quebra de sigilo dos dados telefônicos dos réus (fls. 233/234).

Os réus foram citados e ofereceram resposta prévia a acusação (fls. 254/262 e fls. 389/391).

Durante a instrução, foi tomado o depoimento de uma testemunha, e homologada a dispensa da oitiva de uma testemunha. Após, os réus foram interrogados.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Pleiteou, por fim o perdimento dos valores e do veículo apreendidos e a determinação da perda de função pública de um dos réus.

A defesa do réu Altiéris pugnou pela absolvição. Aduz que a quantidade de entorpecente apreendido é ínfima e, somada às condições de primariedade do réu, não enseja conduta de tráfico; que a suposta droga sintética apreendida é medicamento prescrito (com a finalidade de emagrecimento). Subsidiariamente, requereu benefícios no tocante à pena.

A defesa do réu Wellison pugnou pela absolvição do réu; pela desclassificação do delito de tráfico para uso e, subsidiariamente, requereu benefícios no tocante à pena (termo de audiência fls. 481/483).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17 e fl. 309), laudo de constatação (fls. 41/45, fls. 46/62 e fls. 371/375), laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 212/214, fls. 215/217 e fls. 376/379), relatório de análise de dados- da quebra de sigilo telefônico- (fls. 310/344), bem como pela prova oral produzida em juízo.

O laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 212/214 atestou a presença de cocaína, nas porções de 1,92 gramas, 1,97 gramas e 0,62 gramas de substância ilícita (quantidade total apreendida de 6,2 g de cocaína).

O laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 215/217 atestou a presença de maconha, na porção de 1,96 gramas de substância ilícita (quantidade total apreendida de 27,81 g de tetrahydrocannabinol).

O laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 376/379 identificou o material ácido bórico, na porção de 1,86 gramas de substância química, destacada como de categoria antisséptica e adjuvante farmacêutico, relacionada no rol de ácidos capazes de serem empregados na preparação de drogas.

A autoria, de igual modo, restou demonstrada pela prova oral colhida em juízo.

O policial militar Marcelo narrou que: prestava serviço na companhia de outros policiais, atuando na operação São Paulo mais segura, que visava o bloqueio de ilícitos penais na divisa entre Estados; que, na divisa entre os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, abordaram os réus em um veículo fox; indagado o réu Altiéris afirmou que havia entorpecentes no interior do veículo; durante a vistoria veicular, localizaram 4 porções dos entorpecentes maconha e cocaína e um pacote de ácido bórico, que Altiéris disse usar misturado na cocaína para aumentar a quantidade; além das substâncias, localizaram uma balança de precisão, comprimidos de drogas sintéticas, uma faca e uma quantia em dinheiro; que ambos os réus informaram ter adquirido os entorpecentes na cidade de Brasilândia-MS, e que estavam rumando à cidade de Pauliceia-SP; que parte da droga foi utilizada pelos réus; que Altiéris confessou a venda de entorpecentes na cidade de Pauliceia-SP e o fornecimento a amigos; que os celulares dos réus foram apreendidos, onde foi possível acessar conversas que confirmavam o comércio de entorpecentes; que os entorpecentes estavam separados em pequenas porções, que para o comércio, ainda poderiam ser fracionadas em porções menores; que Altiéris afirmou que adquiriu os entorpecentes, enquanto Wellinson o acompanhava e ajudava na venda, já que estava desempregado; que ambos admitiram o comércio de entorpecentes.

O réu Wellinson, interrogado, narrou que: estava na companhia do réu Altiéris e, antes da abordagem, consumiam o entorpecente em um prato, com auxílio de um canudo, enquanto outra parte estava guardada em um saco plástico; que a balança de precisão era utilizada para pesar e conferir os entorpecentes que adquiriam; que, na época dos fatos, trabalhava como ajudante geral na fazenda de seu genitor e recebia diária de R\$100,00; que passou a relacionar-se com Altiéris, o qual bancava seus consumos de bebidas e drogas; que adquiriam 5 gramas de cocaína pelo preço de R\$200,00; que a maconha foi adquirida em outra oportunidade; desconhece a existência da droga sintética; que utilizava o ácido bórico pra potencializar os efeitos da maconha; que as mensagens capturadas do aplicativo WhatsApp eram relacionadas apenas ao uso de entorpecentes.

O réu Altiéris, interrogado, narrou que: houve abuso policial para que assumisse o tráfico de entorpecentes; que as substâncias apreendidas destinavam-se ao uso; que deslocou-se de Panorama à Brasilândia na companhia de Wellinson, e lá adquiriram 8 gramas de cocaína, pagando o valor de R\$300,00; que utilizaram a balança para pesar a porção de droga adquirida; que adquiriu algumas bebidas e ficou com a quantia de R\$250,00; que todas as substâncias adquiridas foram pagas com dinheiro proveniente de seu trabalho como professor; que a quantia de R\$250,00 apreendida seria utilizada para abastecer o veículo e retornarem à cidade; que os comprimidos apreendidos são medicamentos de uso prescrito; que utiliza a cocaína misturada com

o ácido bórico para potencializar os efeitos; que as mensagens capturadas do aplicativo WhatsApp são provenientes de conversas com pessoas com as quais se relacionava e consumia entorpecentes juntos, e de pessoas de quem adquiria as substâncias; que não comercializava entorpecentes para nenhum de seus contatos; que tinha um relacionamento com o corréu e consumiam drogas juntos.

Pois bem. Quanto ao delito de associação para o tráfico, a versão do policial militar é patente no sentido de que os acusados confessaram a traficância e a viagem anterior para aquisição dos entorpecentes, tendo o réu Altiéris informado a divisão das tarefas, ficando responsável pela aquisição das substâncias, enquanto o corréu Wellinson o acompanhava e auxiliava na venda.

Insta consignar que a estabilidade da *societas sceleris* não se confunde com a reiteração da prática do tráfico, pois, para a configuração do delito em questão, basta uma única ação associativa, vez que o tipo penal fala em prática reiterada ou não. Nessa esteira, o entendimento doutrinário:

[...] a advertência feita no tipo penal (reiteradamente ou não) quer apenas significar que não há necessidade de haver habitualidade, ou seja, não se demanda o cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos arts. 33 e 34, bastando a associação com o fim de cometê-los [...] (NUCCI, Guilherme de Souza. *Leis penais e processuais penais comentadas*, vol. 01, 9ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, p.375)

A união entre os acusados e a presença do mesmo intento criminoso entre ambos pode ser extraída das conversas capturadas do aplicativo de mensagens WhatsApp, onde é possível destacar o seguinte diálogo entre Wellinson e Altiéris:

Réu Wellinson: Porque a creatina pura em si ela dá pra render um terço, já tá ótimo. Agora, quando tava creatina, epinefrina, ácido bórico e cafeína, essa quantidade ia render mais que o dobro.

Qualquer coisa cê fala com o patim então, vê se ele tem, né. Talvez ele não tenha. Já vê quantidade e negocia com ele, aí já pede pra ele deixar pesado, mano. Pra nós chegar lá e catar e vir embora, não ficar enrolando, tendeu?(fl. 330).

Destas conversas, corroborando o que foi dito pelo policial militar no sentido da divisão de ações e da confissão da venda de entorpecentes por ambos, vislumbra-se a tarefa de aquisição para revenda do réu Altiéris, e o esclarecimento quanto à mistura dos entorpecentes com outras substâncias visando a potencialização de seus efeitos e aumento de seu rendimento por Wellinson.

Em caso análogo, assim decidiu o tribunal de justiça bandeirante:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - (ARTS. 33 'CAPUT' E 35 'CAPUT', DA LEI DE DROGAS, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, TODOS NA FORMA DO ART. 69, DO 'CODEX') - (...) Mérito - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos pelo farto conjunto probatório coligido durante a instrução - Interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas, que comprovaram a efetiva participação de todos os recorrentes na prática do tráfico de drogas e respectiva associação - Circunstâncias em que se deram as prisões dos réus, somadas à apreensão de grande quantidade de entorpecente e apetrechos destinados ao preparo e embalagem da droga que dão a certeza do vínculo associativo entre eles, para a prática do comércio ilícito de entorpecentes - Depoimento de policiais - Validade - Negativas dos réus que restaram isoladas nos autos - (...) (TJSP; Apelação Criminal 0085238-17.2012.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022) (grifei)

Apelação - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Recursos defensivos - Provas robustas - Farto acervo investigativo, com interceptações telefônicas - Fornecimento e distribuição de drogas em caráter permanente - Firmes e coerentes depoimentos dos policiais federais responsáveis pela operação - Prova da estabilidade e permanência da associação para o tráfico - Condenações mantidas - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Reincidência, maus antecedentes e associação criminosa que impedem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33

da Lei 11.343/06 - Regime inicial fechado de rigor - Substituição penal não recomendada ao caso - Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 0009981-46.2018.8.26.0156; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cruzeiro - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/09/2022; Data de Registro: 16/09/2022)

Nessa medida, tecidas essas considerações, o ânimo associativo estável e duradouro entre os réus para a prática da traficância ficou sobejamente demonstrado nos autos.

No tocante ao delito de tráfico de entorpecentes, pelo interrogatório dos acusados e demais provas dos autos extrai-se a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11343/06.

Isso porque, em que pese tenham os réus alegado que as substâncias se destinavam ao consumo próprio, as circunstâncias da abordagem, apreensão e da conduta dos acusados não se amoldam ao tipo descrito no artigo 28 da Lei de drogas.

Segue o entendimento do C. STJ:

(...) Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas. (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

E mais:

A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade (TJSP HC 42.229-3. Rel: Onei Raphael)

Com efeito, I) a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes é relevante e não se amolda à conduta de meros usuários (6,2 g de cocaína e 27,81 g de maconha, distribuídos em invólucros, conforme auto de exibição e apreensão); II) a apreensão da substância ácido bórico - que potencializa os efeitos dos entorpecentes e costumeiramente é utilizada na traficância -, e da balança de precisão, de igual modo, utilizada no comércio de entorpecentes; III) a quantia em dinheiro apreendida, IV) a versão do policial militar dando conta de que, durante a abordagem foi esclarecido pelo réu Altiéris a divisão de tarefas com o corréu, V) as mensagens capturadas do aplicativo WhatsApp com teor que evidencia a traficância, confirmam os fatos narrados na denúncia.

No mais, veja-se que os acusados admitem a propriedade dos entorpecentes apreendidos, refutando, apenas, o intento comercial. Entretanto, inviável o reconhecimento de mero status de usuários dadas as circunstâncias acima expostas.

Ademais, não é necessário para a condenação que o réu seja surpreendido em atitude típica de transação comercial ilegal de drogas para se ter como tipificada a conduta descrita no tipo penal, pois o ato de transportar os entorpecentes com a finalidade de entrega a terceiros, como nitidamente era o que os acusados faziam, já caracteriza o crime em questão, pois basta que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

De qualquer modo, é evidente o intento comercial dos acusados, porquanto, o policial militar Marcelo, responsável pela abordagem dos réus e, na condição de testemunha, afirmou que Altiéris confessou o comércio de entorpecentes e pormenorizou a sua conduta com o corréu Wellinson, informando que ficava responsável pela aquisição das substâncias, e Wellinson pelo auxílio na venda.

E, corroborando a palavra do policial militar, após determinada a quebra de sigilo dos dados telefônicos dos acusados, foi possível encontrar em seus aparelhos telefônicos conversas do aplicativo de mensagens WhatsApp que confirmam que ambos se dedicavam à atividade ilícita do comércio de entorpecentes, conforme se verifica dos breves trechos destacados a seguir:

Da conversa entre o réu Wellinson e "Dem":

Dem: Tá ligado, meu mano. Tá ligado. Quando cê tiver pra cá, se tiver tendo alguma coisa dá um salve, pô.

Réu Wellinson: Firmeza, firmeza. Acho que a Carol tá tendo lá ainda, então tenho que ir lá buscar com ela. Buscar o dinheiro e ver o que que sobrou lá. Mas vamos ver final de semana o que que vai ter pa nois (fl. 314).

Posteriormente, há conversa entre o réu Wellinson e "George", onde fica claro uma das vendas especificada em quantidade e valor:

Réu Wellinson: Ô seu George, não. É minha que tá lá. Se o senhor fosse buscar lá, tendeu? Aí eu ia mandar se já pegar umas 3, que é o valor, entendeu? Eu fiz cinquintão cada uma, mas pro senhor eu vou passar as 3 no valor de 100, que é o que eu passo pro senhor sempre (...). O senhor pega e aí o senhor deixa pagar a hora que o senhor me vê, tá? Que aí é pra mim, é minha, tendeu? (fl. 317)

Em seguida, o réu Wellinson conversa com "Jay Pano" com quem esclarece a finalidade de algumas substâncias na traficância:

Réu Wellinson: 10g fazer 20 parada já tá de bom tamanho; dá pra render com produtos (...) e tirar um bom dinheiro (fl. 319)

E, especificamente com o réu Altiéris, o diálogo destacado alhures quanto à associação, no sentido do uso das substâncias conjuntamente com os entorpecentes, potencializando o seu efeito e aumentando a sua quantidade, de igual modo, evidencia o intento comercial entre ambos (fl. 330).

Desta forma, pelo conjunto dos autos, presente, no mínimo, o núcleo "transportar", descrito no caput do artigo 33, da Lei 11343/06, não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para uso.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes - Agentes flagrados trazendo consigo e transportando 84,41 gramas de cocaína sob a forma de "crack", acondicionados em 101 porções -

Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - (...) Tráfico de entorpecentes - Agente que transporta e traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida -

Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 não reconhecida Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constarem dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "transportar" e de "trazer consigo". A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, não devendo ser reconhecida se não se coadunar com a dinâmica dos fatos. (...) Associação para tráfico de entorpecentes - Denúncias anônimas recorrentes relatando a prática do crime - Operação policial que investigou os agentes em campanhas diárias - Depoimentos policiais verossímeis - Prova suficiente A versão de deficiência probatória não sobrevive à análise da prova produzida, considerando-se a apreensão de entorpecente e a prisão em flagrante dos apontados pelas denúncias anônimas.

Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de entorpecentes - Demonstração de união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 Lei n.

11.343/06 É de rigor a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 sempre que verificada a união estável e duradoura entre os acusados, no contexto que antecede o crime de tráfico ilícito de drogas. Em tal situação é,

ainda, incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 do mesmo diploma legal, por incompatibilidade lógica. A associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do agente com atividades criminosas e a

integração de organização criminosa, aspectos que afastam a incidência da referida causa especial de diminuição de pena. Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico - Imposição de privação de liberdade superior a quatro

anos - Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP

Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não

se concebe sua conversão em penas restritivas de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP. (TJSP; Apelação Criminal 1500229-86.2021.8.26.0344; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022) (grifei)

No mais, resta afastada qualquer dúvida acerca do testemunho policial, prova eficaz para a condenação nos crimes de tráfico, conforme a doutrina e a jurisprudência: O tráfico de drogas é crime comumente cometido na clandestinidade. (...) Por conta desse fato, têm como testemunhas, em regra, policiais, cuja palavra merece crédito como a de qualquer outra pessoa. Assim, caberá à defesa o ônus de demonstrar a falta de credibilidade do depoimento de policiais que, até prova em contrário, possui presunção de veracidade e potencial para um édito condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que: "O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 278650/RS, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/06/2016). (Mariano da Silva, César Dário. Lei de Drogas Comentada, 2ª edição, 2016, editora: A.P.M.P. pg. 85)

É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017). (STJ - HC: 530794 SP 2019/0261161-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/08/2020). (grifei)

Em relação à quantidade de drogas, alegada pela defesa como causa que não configura a traficância, ressalto que não pode ser considerada diminuta, pois apta a gerar uma infinidade de unidades para consumo individual:

(...) apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (Apelação n.0000152-73.2017.8.26.0286 5ª Câmara Criminal de São Paulo j.26/10/2017) (STJ; HC 590818-SP; Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; Data da Publicação: 29/06/2020)

No mais, a identificação da substância femproporex como substância anorexígena (fls. 393/396) não modifica o decreto condenatório que pesa contra os acusados diante da apreensão dos entorpecentes maconha e cocaína, além da substância ácido bórico, já destacada, e da inexistência de provas de que o medicamento seja efetivamente utilizado para a finalidade a que se destina, podendo ser investido na mesma função do ácido bórico.

Com relação à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, consigno que resultou devidamente caracterizada, visto que a versão apresentada pelo policial militar é patente no sentido de que as substâncias entorpecentes eram transportadas da cidade de Brasilândia, no Estado do Mato Grosso do Sul, com destino à cidade de Pauliceia localizada no Estado de São Paulo, onde seriam comercializadas. Nessa toada:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL - Art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06 - RECURSO DEFENSIVO - Não discute o mérito - Demonstrada satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime em questão. (...). DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Para a caracterização da causa de aumento decorrente do tráfico interestadual, basta a comprovação da intenção de transpor os limites entre Estados da Federação, situação amplamente comprovada pela prova amealhada aos autos. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1500222-61.2021.8.26.0355; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Miracatu - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022) (grifei).

Tráfico - Suficiência probatória - Condenação mantida. Exasperação das penas-base - Aumento justificado pela enorme quantidade de cocaína - Droga de significativo potencial lesivo - Art. 42 da Lei 11.343/06 - Compensação integral do respectivo acréscimo pela confissão espontânea. Tráfico interestadual - Entorpecente trazido do Mato Grosso do Sul - Caracterização - Majoração mínima. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1500439-83.2021.8.26.0168; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Por fim, incabível a absolvição dos acusados com base na primariedade, porquanto, a ausência de antecedentes criminais não obsta a condenação por delito devidamente comprovado.

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP). Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento dos réus, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime. Impõe-se, portanto, a condenação dos acusados pela prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso V, e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/200.

Os réus são primários, conforme se verifica das certidões de fls. 442/443 e 447/448.

Incabível ao caso a atenuante da confissão pleiteada pela defesa, conforme teor da súmula 630 do STJ:

Súmula 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Passo à dosimetria da pena.

Quanto ao réu ALTIÉRIS:

Na primeira fase, atento ao comando do art. 42 da Lei 11.343 de 2006, inicialmente analiso as circunstâncias judiciais preponderantes: a quantidade da substância não prejudica; a personalidade e a conduta do acusado não prejudicam, ante a inexistência de elementos para aferi-las; a natureza e diversidade das substâncias é prejudicial, porquanto, foram apreendidas as substâncias maconha e cocaína, além do potencializador ácido bórico. Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, como exposto acima, ausentes circunstâncias desfavoráveis. Diante deste panorama, elevo a mínima do delito de tráfico em 1/8, mantendo-se a pena do delito de associação para o tráfico no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis, o que resulta em:

05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 562 dias-multa para o delito de tráfico de drogas; e

03 anos de reclusão e 700 dias multa para o delito de associação para o tráfico.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena provisória se mantém no patamar acima fixado.

Na terceira fase de aplicação da pena, inaplicável a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343 de 2006, uma vez que, comprovado nos autos a associação para fins de tráfico entabulada entre o acusado e o corréu, o que não se amolda à benesse da diminuição.

Ademais, conforme fundamentação já exarada, está plenamente configurada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (tráfico interestadual).

Assim, aumento em 1/6 as penas anteriormente fixadas para o delito de tráfico, obtendo-se o total de:

06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, e 655 dias-multa para o delito de tráfico de drogas; e

03 anos de reclusão e 700 dias multa para o delito de associação para o tráfico.

Por fim, indiscutível o concurso material em razão das infrações terem sido consumadas em momentos inconfundíveis, tendo cada delito ofendido bens jurídicos distintos.

Assim, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas anteriormente obtidas, vez que foram praticadas mediante mais de uma ação ou omissão, implicando-

se no montante definitivo de 09 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, e 1.355 dias multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo legal, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do increpado.

Aplicada pena privativa de liberdade em patamar superior a oito anos, em obediência ao que estabelece o art. 33, § 2º, "a" do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, inaplicável a substituição por penas alternativas, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e, da mesma forma, inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal.

Quanto ao réu WELLINSON:

Na primeira fase, atento ao comando do art. 42 da Lei 11.343 de 2006, inicialmente, analiso as circunstâncias judiciais preponderantes: a quantidade da substância não prejudica; a personalidade e conduta do acusado não prejudicam, ante a inexistência de elementos para aferi-la; a natureza e diversidade das substâncias é prejudicial, porquanto, foram apreendidas as substâncias maconha e cocaína, além do potencializador ácido bórico. Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, como exposto acima, ausentes circunstâncias desfavoráveis. Diante deste panorama, elevo a mínima do delito de tráfico em 1/8, mantendo-se a pena do delito de associação para o tráfico no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis, o que resulta em:

05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 562 dias-multa para o delito de tráfico de drogas; e

03 anos de reclusão e 700 dias multa para o delito de associação para o tráfico.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena provisória se mantém no patamar acima fixado.

Na terceira fase de aplicação da pena, inaplicável a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343 de 2006, uma vez que, comprovado nos autos a associação para fins de tráfico entabulada entre o acusado e o corréu, o que não se amolda à benesse da diminuição.

Ademais, conforme fundamentação já exarada, está plenamente configurada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (tráfico interestadual). Assim, aumento em 1/6 as penas anteriormente fixadas para o delito de tráfico, obtendo-se o total de:

06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, e 655 dias-multa para o delito de tráfico de drogas; e

03 anos de reclusão e 700 dias multa para o delito de associação para o tráfico.

Por fim, indiscutível o concurso material em razão das infrações terem sido consumadas em momentos inconfundíveis, tendo cada delito ofendido bens jurídicos distintos.

Assim, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas anteriormente obtidas, vez que foram praticadas mediante mais de uma ação ou omissão, implicando-se no montante definitivo de 09 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, e 1.355 dias multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo legal, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do increpado.

Aplicada pena privativa de liberdade em patamar superior a oito anos, em obediência ao que estabelece o art. 33, § 2º, "a" do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, inaplicável a substituição por penas alternativas, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e, da mesma forma, inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para: CONDENAR o acusado ALTIÉRIS DE SOUZA SILVA à pena de 09 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.355 dias-multa, como incurso nos crimes descritos pelo artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso V; e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/2006; e CONDENAR o acusado WELLINSON DOS SANTOS MENEZES à pena de 09 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.355 dias-multa, como incurso nos crimes descritos pelo artigo 33, caput, cumulado com o

artigo 40, inciso V; e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/2006.

Os acusados encontram-se presos preventivamente desde a data em que ocorrera o crime, não tendo a instrução processual revelado nada no sentido da modificação do quadro fático em que se apoiou a decretação da prisão provisória, restando revigorados os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de custodiá-los para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO.

FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO

DESPROVIDO. (...)9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

Assim sendo, NEGO AOS ACUSADOS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Recomende-se.

Interposto recurso pelas defesas ou acusação, expeça-se Guia de Recolhimento provisória, a fim de que sejam analisadas as possibilidades da concessão de

eventuais benefícios aos acusados pelo Juízo das Execuções Penais, observando-se o que dispõe o art. 470 das Normas de Serviço.

Custas pelos réus, com exequibilidade suspensa em razão da gratuidade ora concedida.

Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei 11.343/06.

Determino o perdimento dos valores apreendidos e depositados às fls. 211 em favor das instituições conveniadas a este Juízo.

No tocante ao veículo Fox, ano 2010, cor preta, placas ASD-5177/Bastos-SP, verifico que, considerando a sua legítima propriedade e uso lícito, já foi restituído à proprietária Luzia dos Santos de Souza, sendo inviável o seu perdimento (conforme decisão de fl. 42 e auto de entrega de fls. 50/54 dos autos em apenso nº 0000712-37.2022.8.26.0416).

Quanto à perda da função pública do réu Altiéris, a despeito da pena aplicada ser superior a 4 anos, com espeque no que dispõe o artigo 92 do CP (necessidade de motivação para a decretação), indefiro o pedido de decretação de perda da função pública por inexistir elementos que demonstrem que o acusado utilizava-se da condição de professor como meio facilitador para o tráfico, ou que tenha sido autuado em flagrante no exercício da função.

Após o trânsito em julgado, providencie a serventia a (o):

1) Caso exista pena de multa, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, e, após, intime-se os acusados para comprovar nos autos o respectivo pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de encaminhamento de certidão da sentença ao Ministério Público, providência esta que deve ser adotada também na hipótese em que for infrutífera a tentativa de intimação (art. 50 do CP e art. 479 e seguinte das NSCGJ);

2) anotação da condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial (art. 372 das NSCGJ);

3) expedição de ofício ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ);

4) expedição de ofício ao TRE, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 398, II, das NSCGJ);

5) expedição de certidão de honorários ao defensor nomeado (ofício fl. 358), no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários do convênio DPESP/OABSP;

6) expedição da guia definitiva.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

P.I.C.

Panorama, 02 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA